فرم پیشنهادی پایان نامه

(طرح پژوهشی نوع ششم)

کارشناسی ارشد ☐ دکتری ☐

شماره طرح:

شماره طرح، توسط معاونت پژوهشی دانشگاه هنگام صدور ابلاغ درج خواهد شد.

خلاصه اطلاعات طرح

عنوان طرح به زبان فارسی:

مطالعه ضمانت اجراهای حقوقی و قراردادی عدم تامین منابع مالی مورد تعهد یک عضو مشارکت در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی با تاکید بر مسئولیت مشارکت در برابر سرمایه‌پذیر دولتی

عنوان طرح به زبان انگلیسی:

A Study of Legal and Contractual Remedies for a Joint Venture Member’s Failure to Provide Committed Funding in International Investment Contracts, with Emphasis on the Joint Venture Members’ Liability to the State Investment Recipient

نوع طرح: بنیادی ☐ کاربردی ☐ توسعه ای ☐

میزان اعتبار مصرفی و سرمایه ای از محل بودجه پژوهشی:

تاریخ پیشنهادی طرح:

تاریخ تصویب طرح (در شورای تحصیلات تکمیلی ـ پژوهشی گروه):

اطلاعات استاد راهنما و مشاورین

نوع مسولیت	نام و نام خانوادگی	مرتبه علمی	محل خدمت	امضاء
استاد راهنما (مجری)	جناب دکتر عبدالحسین شیروی	استاد	دانشگاه تهران	
استاد راهنما دوم (حسب مورد)				
استاد مشاور				
استاد مشاور دوم (برای دکتری)				

اطلاعات دانشجو

نام و نام خانوادگی: فاطمه امین

گروه: حقوق خصوصی

شماره دانشجویی: ۲۱۰۵۰۱۰۰۳

رشته تحصیلی: حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین‌المللی

مقطع تحصیلی: دکتری

تعریف مساله، اهداف و ضرورت اجرای طرح:

اجرای بسیاری از پروژه های سرمایه گذاری بین المللی در حوزه هایی مانند انرژی، معادن و زیرساخت ها به منابع مالی قابل توجه و همکاری شرکت هایی نیاز دارد که از توان مالی و اجرایی متفاوتی برخوردار هستند. در چنین پروژه هایی، تشکیل کنسرسیوم یا مشارکت مشترک به سرمایه گذاران امکان می دهد منابع و امکانات خود را برای اجرای یک قرارداد معین در اختیار مشارکت قرار دهند و درباره سهم هر عضو از سرمایه گذاری و تعهدات مربوط به اجرای پروژه توافق کنند (ICC, 2024a, 2024b). در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی که میان یک نهاد دولتی و کنسرسیوم یا مشارکت مشترک منعقد می شود، تعهدات مالی اعضا معمولا در توافق داخلی مشارکت تقسیم می شود و هر عضو موظف است سهم مورد توافق خود را در زمان مقرر تامین کند. در مقابل، ممکن است قرارداد اصلی سرمایه گذاری اعضای کنسرسیوم را نسبت به اجرای تعهدات قراردادی در برابر سرمایه‌پذیر دولتی منفردا و متضامنا مسئول شناخته باشد. در این وضعیت، تعهد مالی هر عضو در برابر سایر اعضا و مسئولیتی که همان عضو در برابر طرف دولتی پذیرفته است، از دو رابطه قراردادی ناشی می شود و دامنه آنها بر اساس مفاد هر قرارداد تعیین می گردد. در قرارداد نمونه کنسرسیوم اتاق بازرگانی بین المللی، مسئولیت اعضا در برابر کارفرما به صورت تضامنی پیش بینی شده و تقسیم تعهدات در روابط داخلی نیز تابع توافق میان اعضاست (ICC, 2024). این ساختار زمانی با دشواری حقوقی مواجه می شود که یکی از اعضا سهم مالی مورد تعهد خود را تامین نمی کند و سایر اعضا باید درباره جبران کسری منابع تصمیم بگیرند، در شرایطی که تعهدات پذیرفته شده در قرارداد اصلی همچنان بر عهده اشخاص مشمول شرط تضامن قرار دارد. در چنین وضعیتی، تعیین حقوق سایر اعضا نسبت به عضو پرداخت نکرده و حدود مسئولیت آنان در برابر سرمایه‌پذیر دولتی، مستلزم توجه به مفاد هر دو قرارداد و آثار حقوقی عدم تامین منابع مالی است (Mahasneh, 2024).

تامین نشدن منابع مالی مورد تعهد ممکن است در نتیجه خودداری عضو از پرداخت با وجود توانایی مالی، ناتوانی در تامین وجه یا بروز موانعی باشد که اجرای تعهد را در موعد مقرر تحت تاثیر قرار داده اند. در تمام این وضعیت ها، سهم مالی عضو در زمان پیش بینی شده در اختیار مشارکت قرار نگرفته است، ولی علت وقوع عدم تامین می تواند در تعیین مسئولیت قراردادی و حقوق سایر اعضا اثر متفاوتی داشته باشد. ماده ۷.۱.۱ اصول قراردادهای تجاری بین المللی یونیدروا، مفهوم عدم اجرای تعهد را شامل انجام نشدن کامل، اجرای ناقص و اجرای با تاخیر می داند و مواردی را که عدم اجرا با عذر قابل پذیرش همراه است نیز در همین مفهوم قرار می دهد (UNIDROIT, 2016, Art. 7.1.1). در خصوص معافیت از مسئولیت نیز ماده ۷.۱.۷، شرایطی مانند خارج بودن مانع از اختیار

متعهد و امکان نداشتن پیش بینی یا رفع متعارف آن را مقرر کرده است (UNIDROIT, 2016, Art. 7.1.7). بر همین مبنا، ناتوانی مالی عضو یا وجود محدودیت در دسترسی به منابع، به تنهایی وضعیت مسئولیت او را تعیین نمی کند و باید روشن شود که مفاد تعهد مالی، علت عدم پرداخت و شرایط مقرر در قرارداد و قانون حاکم، چه اثری بر استمرار تعهد و مسئولیت ناشی از عدم انجام آن دارند. این تفکیک به ویژه درباره ضمانت اجراهایی اهمیت حقوقی پیدا می کند که اعمال آنها به صرف عدم پرداخت، انقضای مهلت قراردادی یا احراز شرایط دیگری وابسته شده است.

آثار عدم تامین منابع مالی ابتدا در روابط داخلی اعضای مشارکت ظاهر می شود، زیرا مبلغ پرداخت نشده ممکن است برای انجام هزینه هایی لازم باشد که قبلا در بودجه پروژه پیش بینی شده و سایر اعضا بر اساس سهم تعهدشده خود برای تامین آنها برنامه ریزی کرده اند. در این شرایط، ادامه اجرای برنامه مالی مشارکت می تواند به تامین کسری از سوی اعضای دیگر وابسته شود و پرداخت مبلغ اضافی نیز درباره بازپرداخت آن و تقسیم نهایی هزینه ها تعهدات تازه ای ایجاد کند. در راهنمای تنظیم توافق های مشارکت مشترک بانک جهانی، تعیین آورده اولیه، تعهدات تامین سرمایه اضافی، وام اعضا به مشارکت و شرایط خروج در صورت نقض تعهدات، از موضوعاتی است که باید در توافق میان اعضا تنظیم شود (World Bank, n.d.-b). همچنین در نمونه توافق توسعه مشترک منتشرشده در پایگاه بانک جهانی، پرداخت سهم هزینه ها در پاسخ به درخواست تامین وجه پیش بینی شده و برای ادامه عدم پرداخت، سازوکارهایی از جمله تهاتر بدهی با مطالبات عضو و تغییر وضعیت مشارکت او مقرر شده است (World Bank, n.d.-a). با توجه به تفاوت آثار این اقدامات، باید تعیین شود که تامین کسری منابع توسط سایر اعضا چه ماهیت حقوقی دارد، در چه شرایطی برای آنان حق مطالبه ایجاد می کند و مبلغی که هر عضو می تواند از عضو مسئول دریافت کند چگونه تعیین می شود. این موضوع زمانی پیچیده تر می شود که توافق داخلی، جبران هزینه های تامین مالی یا دریافت خسارت قراردادی را نیز پیش بینی کرده باشد و چند مطالبه مالی ناشی از یک مورد عدم تامین منابع مطرح شود.

ضمانت اجراهای قراردادی ممکن است فراتر از مطالبه مبلغ پرداخت نشده یا جبران خسارت باشند و بر میزان سهم و حقوق عضویت شخصی که تعهد مالی خود را انجام نداده است اثر بگذارند. کاهش سهم مشارکت، محدودیت حق رای، انتقال اجباری سهم و خروج عضو از جمله اقداماتی هستند که در توافق های مشارکت برای وضعیت عدم اجرای تعهدات پیش بینی می شوند و اجرای هر یک می تواند ترکیب حقوق مالی و مدیریتی اعضا را تغییر دهد. در نمونه توافق توسعه مشترک بانک جهانی، کاهش سهم عضو به میزان هزینه های تامین شده توسط اعضا وابسته شده و خروج اجباری نیز به عنوان اقدامی جداگانه در صورت استمرار وضعیت قراردادی مقرر پیش بینی شده است

(World Bank, n.d.-a). از نظر حقوقی، امکان پیش بینی چنین ضمانت اجراهایی پرسش های دیگری درباره حدود آزادی قراردادی اعضا، شرایط اعمال اختیار کاهش یا انتقال سهم و نحوه تعیین ارزش حقوق مالی عضو ایجاد می کند. در حقوق انگلستان، رای دیوان عالی در پرونده Cavendish Square Holding BV v Makdessi نشان می دهد که ارزیابی شروط انتقال اجباری سهام و تعیین عوض انتقال می تواند به ماهیت تعهد قراردادی و منفعت مشروعی وابسته باشد که شرط برای حمایت از آن مقرر شده است (UK Supreme Court, 2015). از سوی دیگر، ماده ۷.۴.۱۳ اصول یونیدروا، درباره مبالغ از پیش تعیین شده برای عدم اجرای تعهد، امکان کاهش مبلغ قراردادی را در صورت نامتناسب بودن شدید آن با زیان و اوضاع و احوال پیش بینی می کند (UNIDROIT, 2016, Art. 7.4.13). این تفاوت در مبانی حقوقی، تعیین شرایط اعتبار هر ضمانت اجرا را به مسئله ای مستقل از توافق اولیه اعضا درباره اصل تعهد مالی تبدیل می کند.

در قراردادهایی که سرمایه‌پذیر دولتی اعضای کنسرسیوم را منفردا و متضامنا مسئول اجرای تعهدات شناخته است، آثار عدم تامین منابع مالی یک عضو به وضعیت اجرای قرارداد اصلی نیز وابسته می شود. مسئولیت تضامنی به طرف دولتی اجازه می دهد اجرای تعهدات مشمول این شرط را بر اساس قرارداد از هر یک از اعضای مسئول مطالبه کند و تقسیم داخلی سهم مالی اعضا، به خودی خود دامنه حق مطالبه ناشی از قرارداد اصلی را تغییر نمی دهد. ماده ۱۱.۱.۳ اصول یونیدروا مقرر می کند که طلبکار می تواند تا زمان اجرای کامل تعهد، اجرای آن را از هر یک از متعهدان تضامنی درخواست کند (UNIDROIT, 2016, Art. 11.1.3). در قراردادهای مبتنی بر شرایط فیدیک نیز اعضای مشارکت مشترک در برابر کارفرما نسبت به اجرای تعهدات پیمانکار مسئولیت تضامنی دارند و قلمرو این مسئولیت با توجه به تعهدات مقرر در قرارداد و قواعد حقوقی حاکم تعیین می شود (Mahasneh, 2024). در وضعیت مورد بحث، لازم است معلوم شود تامین نشدن سهم مالی یک عضو چه زمانی بر اجرای تعهدات قرارداد اصلی اثر می گذارد، زیرا ممکن است کسری منابع از طریق پرداخت سایر اعضا جبران شده باشد یا تاخیر در تامین آن موجب عدم اجرای تعهدی شود که کنسرسیوم در برابر سرمایه‌پذیر دولتی پذیرفته است. تعیین این موضوع بر حق مطالبه نهاد دولتی، حدود مسئولیت سایر اعضا و آثار پرداخت هایی که برای ادامه اجرای قرارداد انجام می شود تاثیر دارد.

پذیرش مسئولیت تضامنی همچنین سبب می شود عضوی که بیش از سهم داخلی خود برای اجرای تعهد مشترک پرداخت کرده است، در رابطه با سایر اعضا دارای موقعیت حقوقی متفاوتی شود. طبق ماده ۱۱.۱.۱۰ اصول یونیدروا، متعهد تضامنی که بیش از سهم خود تعهد را اجرا کرده، می تواند مبلغ

اضافی را در حدود سهم پرداخت نشده هر یک از سایر متعهدان از آنان مطالبه کند (UNIDROIT, 2016, Art. 11.1.10). با این حال، در مشارکت سرمایه گذاری باید میان مبلغی که عضو برای ایفای تعهد مالی داخلی شریک خود پرداخت کرده و مبلغی که برای اجرای مسئولیت تضامنی در برابر سرمایه‌پذیر دولتی پرداخته است، از نظر مبنای ایجاد حق رجوع تفکیک شود. تعهد عضو به تامین سهم مالی در توافق داخلی ممکن است شرایط بازپرداخت، خسارت یا تبدیل مبلغ تامین شده به طلب قراردادی را تعیین کرده باشد و اجرای تعهد تضامنی نیز تابع قواعد مربوط به تعدد متعهدان و تقسیم نهایی مسئولیت میان آنان است. از این جهت، پرداخت کسری منابع مالی توسط سایر اعضا دو پرسش حقوقی به همراه دارد که یکی به امکان مطالبه مبلغ پرداخت شده از عضو مسئول و دیگری به اثر همان پرداخت بر تعهدات مشارکت در برابر سرمایه‌پذیر دولتی مربوط می شود. پاسخ هر دو پرسش به تشخیص تعهدی بستگی دارد که پرداخت برای اجرای آن انجام شده و حقوقی که از قرارداد مربوط یا قواعد حقوقی حاکم ناشی می شود.

موضوع زمانی ابعاد قراردادی بیشتری پیدا می کند که سایر اعضا در نتیجه استمرار عدم تامین منابع مالی، تصمیم به کاهش سهم عضو، انتقال اجباری تمام سهم او یا خروج وی از مشارکت بگیرند. در این وضعیت، تصمیمی که مطابق توافق داخلی اعضا اتخاذ شده است، ممکن است موجب تغییر ترکیب کنسرسیومی شود که قرارداد اصلی سرمایه گذاری را با نهاد دولتی منعقد کرده است. از آنجا که تعهدات قرارداد اصلی بر اساس حضور اعضای معین و مسئولیت آنان پذیرفته شده، قرارداد سرمایه گذاری می تواند خروج، جایگزینی یا انتقال موقعیت قراردادی عضو را به موافقت قبلی سرمایه‌پذیر دولتی وابسته کند. بند ۱.۱۴ شرایط عمومی قراردادهای فیدیک، تغییر اعضا و وضعیت حقوقی مشارکت را به موافقت کارفرما مشروط کرده و آثار این موافقت بر مسئولیت تضامنی را نیز مورد توجه قرار داده است (Mahasneh, 2024). بر همین اساس، ممکن است توافق داخلی شرایط انتقال اجباری سهم را فراهم کرده باشد و در عین حال تکمیل تغییر موقعیت قراردادی عضو در برابر نهاد دولتی به رعایت تشریفات دیگری نیاز داشته باشد. در چنین وضعیتی، تعیین آثار عدم موافقت سرمایه‌پذیر دولتی بر اجرای تصمیم داخلی، وضعیت حقوقی عضو تا زمان تکمیل انتقال و استمرار مسئولیت او نسبت به تعهدات قبلی، از موضوعات حقوقی ناشی از اعمال ضمانت اجرای عدم تامین منابع مالی خواهد بود.

در مقررات قراردادی مربوط به مشارکت های سرمایه گذاری، شرایط تامین سهم مالی، ضمانت اجراهای عدم پرداخت، مسئولیت اعضا در برابر طرف قرارداد و محدودیت های تغییر ترکیب مشارکت در قالب شروطی تنظیم می شوند که هر کدام به بخشی از رابطه حقوقی طرف ها اختصاص دارند. نمونه توافق توسعه مشترک بانک جهانی، آثار عدم انجام تعهدات مالی بر سهم و

عضویت را تنظیم کرده است (World Bank, n.d.-a) و قرارداد نمونه کنسرسیوم اتاق بازرگانی بین المللی نیز مسئولیت تضامنی اعضا در برابر کارفرما را در کنار تقسیم مسئولیت های داخلی پیش بینی می کند (ICC, 2024). در سطح قواعد عمومی تعهدات، اصول یونیدروا شرایط عدم اجرای قرارداد و حقوق متعهدان تضامنی را بیان کرده است (UNIDROIT, 2016) و در شرایط فیدیک، موافقت کارفرما با تغییر ترکیب مشارکت بر آثار حقوقی خروج یا جایگزینی عضو تاثیر می گذارد (Mahasneh, 2024). با کنار هم قرار گرفتن این مقررات، تعیین آثار عدم تامین منابع مالی یک عضو مستلزم پاسخ به این موضوع است که حقوق ناشی از توافق داخلی تا چه اندازه قابلیت اجرا دارند و اعمال آنها تحت چه شرایطی می تواند وضعیت تعهدات پذیرفته شده در قرارداد اصلی را تغییر دهد. در واقع، امکان مطالبه سهم مالی، جبران کسری، کاهش یا انتقال سهم و خروج عضو، هر یک آثار حقوقی متفاوتی دارد و وجود مسئولیت تضامنی و شرط موافقت سرمایه‌پذیر دولتی، حدود اجرای این اقدامات را در رابطه با قرارداد اصلی تحت تاثیر قرار می دهد.

با توجه به این وضعیت، تعیین ضمانت اجراهای عدم تامین منابع مالی در مشارکت های طرف قرارداد با نهادهای دولتی، مستلزم روشن شدن چند موضوع حقوقی وابسته به یکدیگر است. ابتدا باید آثار علت تامین نشدن منابع بر مسئولیت عضو تعیین شود تا شرایط مطالبه تعهد مالی و جبران خسارت بر مبنای وضعیت قراردادی او روشن گردد. در ادامه، ضمانت اجراهای مالی و شروط موثر بر حقوق عضویت و سهم باید از نظر شرایط اعمال و حدود اعتبار حقوقی بررسی شوند، زیرا اجرای آنها می تواند از ایجاد یک طلب مالی تا انتقال اجباری حقوق عضو متفاوت باشد. در همین رابطه، مسئولیت منفرد و تضامنی اعضا در برابر سرمایه‌پذیر دولتی تعیین می کند که عدم تامین منابع توسط یک عضو چه آثاری بر اجرای تعهدات قرارداد اصلی دارد و طرف دولتی تحت چه شرایطی می تواند اجرای تعهدات را از سایر اعضا مطالبه کند. در نهایت، شرایط موافقت سرمایه‌پذیر دولتی با خروج یا انتقال سهم نیز بر امکان تغییر ترکیب مشارکت و تعیین اشخاص مسئول پس از این تغییر اثر خواهد گذاشت. مجموعه این موضوعات، بررسی ضمانت اجراهای عدم تامین منابع مالی را به وضعیت قراردادی معینی محدود می کند که در آن حقوق اعضا در برابر یکدیگر و مسئولیت آنان در برابر سرمایه‌پذیر دولتی باید بر اساس تعهدات پذیرفته شده و قواعد حقوقی حاکم تعیین شود. مطالعات پیشین بخش هایی از تعهدات مالی اعضای مشارکت، ضمانت اجراهای عدم پرداخت سهم و مسئولیت تضامنی در قراردادهای مشترک را بررسی کرده اند (شیروی و عباسی وفایی، ۱۴۰۱؛ پریرا، ۲۰۱۹؛ ماهسنه، ۲۰۲۴)، با این حال، آثار حقوقی عدم تامین منابع مالی یک عضو در وضعیتی که اعضای کنسرسیوم در برابر سرمایه‌پذیر دولتی مسئولیت منفرد و تضامنی دارند، همچنان نیازمند بررسی یکپارچه است. در این وضعیت، تعیین شرایط اعمال ضمانت اجراهای مالی و ضمانت

اجراهای موثر بر حقوق عضویت و سهم، با این پرسش همراه است که اجرای این ضمانت اجراها چه تاثیری بر تعهدات پذیرفته شده در قرارداد اصلی دارد و لزوم موافقت سرمایه‌پذیر دولتی تا چه اندازه می تواند خروج عضو یا انتقال سهم او را محدود کند. همچنین آثار تفاوت علت عدم تامین منابع مالی بر مسئولیت عضو و وضعیت مسئولیت سایر اعضا پس از جبران کسری منابع، در چارچوب این دو رابطه قراردادی نیازمند تعیین است. پژوهش حاضر با بررسی تطبیقی قواعد حقوقی حاکم بر روابط داخلی اعضا و قرارداد اصلی سرمایه گذاری، شرایط اعمال ضمانت اجراها، حدود مسئولیت تضامنی و آثار موافقت سرمایه‌پذیر دولتی بر تغییر ترکیب مشارکت را در همین وضعیت قراردادی تحلیل می کند.

سوالات تحقیق:

سوال اصلی

در صورت عدم تامین منابع مالی مورد تعهد یکی از اعضای مشارکت در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی، ضمانت اجراهای حقوقی و قراردادی با توجه به مسئولیت منفرد و تضامنی اعضا در برابر سرمایه‌پذیر دولتی تحت چه شرایطی قابل اعمال هستند؟

سوالات فرعی

۱. علت عدم تامین منابع مالی مورد تعهد چه تاثیری بر مسئولیت قراردادی عضو در روابط داخلی مشارکت دارد؟

۲. در صورت عدم تامین منابع مالی مورد تعهد یکی از اعضا، چه ضمانت اجراهای مالی علیه او در روابط داخلی مشارکت قابل اعمال است؟

۳. ضمانت اجراهای موثر بر حقوق عضویت و سهم مشارکت عضوی که منابع مالی مورد تعهد خود را تامین نکرده است، تحت چه شرایط حقوقی و قراردادی قابل اعمال هستند؟

۴. در صورت عدم تامین منابع مالی مورد تعهد توسط یکی از اعضا، حدود مسئولیت منفرد و تضامنی اعضای مشارکت در برابر سرمایه‌پذیر دولتی چگونه تعیین می‌شود؟

۵. لزوم موافقت سرمایه‌پذیر دولتی چه اثری بر اجرای ضمانت اجراهای منتهی به خروج عضو یا انتقال سهم او از مشارکت دارد؟

فرضیات تحقیق:

در صورت عدم تامین منابع مالی مورد تعهد یکی از اعضای مشارکت، قابلیت اعمال ضمانت اجراهای مالی و ضمانت اجراهای موثر بر حقوق عضویت و سهم، با توجه به علت عدم تامین و شرایط مقرر در توافق داخلی و حقوق حاکم تعیین می‌شود و آثار اجرای این ضمانت اجراها بر مسئولیت منفرد و تضامنی اعضا در برابر سرمایه‌پذیر دولتی، تابع مفاد قرارداد اصلی سرمایه گذاری و الزامات قراردادی مربوط به موافقت آن نهاد با خروج عضو یا انتقال سهم خواهد بود.

روش و فنون اجرایی طرح:

پژوهش حاضر از نظر ماهیت، حقوقی و از نظر روش، توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی است و اطلاعات مورد نیاز به شیوه کتابخانه ای و اسنادی گردآوری می شود. بررسی بر قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی متمرکز است که در آنها یک کنسرسیوم یا مشارکت مشترک، طرف قرارداد با سرمایه‌پذیر دولتی قرار گرفته و اعضای آن مسئولیت منفرد و تضامنی اجرای تعهدات قرارداد اصلی را پذیرفته اند. در این ساختار، هر عضو براساس توافق داخلی مشارکت، تعهد معینی برای تامین سهم خود از منابع مالی سرمایه گذاری دارد. واحد تحلیل پژوهش، تعهد مالی عضو و آثار حقوقی عدم تامین آن در روابط داخلی اعضای مشارکت و قرارداد اصلی منعقدشده با سرمایه‌پذیر دولتی است. قواعد حقوقی حاکم بر این دو رابطه با روش تحلیل دکترینال بررسی می شوند و مطالعه تطبیقی در چارچوب حقوق ایران و انگلستان انجام می گیرد (Hutchinson & Duncan, 2012; Michaels, 2019).

منابع پژوهش شامل قوانین و مقررات، قراردادهای نمونه بین المللی، آرای قضایی و منابع حقوقی مرتبط با تعهدات مالی اعضای مشارکت، ضمانت اجراهای قراردادی و مسئولیت تضامنی است. در حقوق ایران، مواد ۱۰ و ۲۱۹ تا ۲۳۰ قانون مدنی در زمینه تعهدات قراردادی و مسئولیت ناشی از عدم اجرای آنها و مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت درباره مسئولیت تضامنی بررسی می شود. در حقوق انگلستان، قواعد حقوق قراردادها و آرای قضایی مربوط به عدم اجرای تعهدات مالی، خسارت قراردادی، انتقال اجباری سهم و سلب حقوق قراردادی مورد مطالعه قرار می گیرد. اسناد قراردادی مورد بررسی نیز شامل قراردادهای نمونه کنسرسیوم و مشارکت مشترک اتاق بازرگانی بین المللی، قرارداد نمونه عملیات مشترک AIEN 2023 و نمونه توافق های مشارکت منتشرشده توسط بانک جهانی است. از این اسناد، شروط مربوط به تامین منابع مالی، عدم پرداخت سهم، ضمانت اجراهای مالی، تغییر حقوق عضویت، مسئولیت اعضا و شرایط خروج یا انتقال سهم استخراج می شود. اصول قراردادهای تجاری بین المللی یونیدروا مصوب ۲۰۱۶ نیز در بررسی قواعد عدم اجرای تعهد، مسئولیت تضامنی، حق رجوع و انتقال تعهدات قراردادی مورد استفاده قرار می گیرد (UNIDROIT, 2016).

در مرحله نخست، ماهیت و شرایط تعهد اعضا به تامین منابع مالی بررسی می شود. برای این منظور، مقررات قراردادی مربوط به میزان سهم مالی هر عضو، نوع تعهد، موعد پرداخت، شرایط درخواست منابع و تعهدات مربوط به تامین سرمایه اضافی استخراج خواهد شد. سپس شرایط تحقق عدم تامین منابع مالی با توجه به مبلغ تعهدشده، پرداخت های انجام شده و سررسید مقرر در قرارداد مورد بررسی قرار می گیرد. آثار علت عدم تامین بر مسئولیت عضو نیز در سه وضعیت خودداری از پرداخت با وجود توانایی مالی، ناتوانی در تامین منابع و وجود موانع خارج از اختیار عضو تحلیل می شود. در هر وضعیت، مفاد تعهد قراردادی با قواعد مسئولیت ناشی از عدم اجرای تعهد و شرایط استناد به معاذیر قراردادی در حقوق ایران و انگلستان تطبیق داده خواهد شد. مواد ۷.۱.۱ و ۷.۱.۷ اصول یونیدروا نیز در بررسی مفهوم عدم اجرا و شرایط معافیت ناشی از موانع اجرای تعهد مورد استفاده قرار می گیرند (UNIDROIT, 2016).

در مرحله دوم، ضمانت اجراهای مالی در روابط داخلی اعضای مشارکت بررسی می شوند. ابتدا شروط مربوط به مطالبه منابع مالی پرداخت نشده، الزام عضو به اجرای تعهد، جبران خسارت و وجه التزام استخراج شده و شرایط اعمال هر یک براساس توافق داخلی و قانون حاکم تحلیل می شود. در مورد خسارت، مبنای مسئولیت، شرایط مطالبه و حدود زیان قابل جبران و در مورد وجه التزام، مبلغ یا فرمول قراردادی تعیین خسارت و شرایط اجرای شرط بررسی خواهد شد. سپس مقررات مربوط به تامین کسری منابع مالی توسط سایر اعضا مطالعه می شود و ماهیت حقوقی پرداخت های انجام شده، شرایط بازپرداخت و مبنای ایجاد حق رجوع مورد تحلیل قرار می گیرد. در مواردی که تامین کسری در قالب وام انجام شده باشد، تعهد بازپرداخت، سررسید و حقوق اعضای پرداخت کننده بررسی می شود. شروط مربوط به تهاتر مطالبات با حقوق مالی عضو نیز از نظر شرایط اعمال و آثار آن بر تعهدات مالی طرفین مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

در مرحله سوم، ضمانت اجراهای موثر بر حقوق عضویت و سهم مشارکت بررسی می شوند. شروط مربوط به تعلیق حق رای و محدودیت حقوق مدیریتی از نظر شرایط اعمال، اختیار تصمیم گیری و مدت محدودیت تحلیل خواهند شد. سپس مقررات کاهش سهم مشارکت، انتقال اجباری سهم و خروج عضو به صورت مستقل مورد بررسی قرار می گیرند. در خصوص کاهش سهم، مبنای قراردادی تغییر درصد مشارکت و شیوه محاسبه سهم جدید استخراج می شود و در بررسی انتقال اجباری، شرایط ایجاد حق انتقال، اشخاص دارای حق خرید، روش ارزش گذاری سهم، کسورات قراردادی و عوض قابل پرداخت مورد توجه قرار می گیرد. شروط مربوط به سلب بلاعوض سهم نیز براساس ماهیت حقوقی و شرایط اجرای آنها بررسی خواهند شد. اعتبار و قابلیت اجرای هر ضمانت اجرا با استفاده از قواعد حقوق ایران و انگلستان تحلیل می شود. در حقوق انگلستان، رأی Cavendish Square Holding BV v Makdessi [2015] UKSC 67 برای بررسی قواعد شروط کیفری و رأی

Cukurova Finance International Ltd v Alfa Telecom Turkey Ltd [2013] UKPC 2 برای بررسی قواعد انصاف مرتبط با سلب حقوق مالکانه مورد استفاده قرار می گیرد.

در مرحله چهارم، مسئولیت منفرد و تضامنی اعضای مشارکت در برابر سرمایه‌پذیر دولتی بررسی می شود. در این بخش، شرط مسئولیت تضامنی در قرارداد اصلی از نظر اشخاص مسئول، تعهدات مشمول تضامن و حدود حق مطالبه طرف دولتی تحلیل خواهد شد. سپس وضعیت عدم تامین منابع مالی توسط یکی از اعضا از نظر تاثیر آن بر اجرای تعهدات قرارداد اصلی مورد بررسی قرار می گیرد. در مواردی که سایر اعضا کسری منابع مالی را تامین کرده اند، مقررات مربوط به آثار پرداخت بر تعهدات مشارکت در برابر سرمایه‌پذیر دولتی مطالعه می شود. همچنین مفاد توافق داخلی درباره تقسیم سهم مالی و پرداخت های انجام شده توسط اعضا، در کنار شرط مسئولیت تضامنی قرارداد اصلی بررسی خواهد شد. مبنای حقوقی این تحلیل در حقوق ایران، مقررات مسئولیت تضامنی قانون تجارت و در اصول یونیدروا، مواد ۱۱.۱.۱ تا ۱۱.۱.۱۰ درباره تعدد متعهدان، حق مطالبه طلبکار و حق رجوع میان متعهدان تضامنی است (UNIDROIT, 2016).

در مرحله پنجم، مقررات مربوط به خروج عضو یا انتقال سهم او با توجه به لزوم موافقت سرمایه‌پذیر دولتی مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا شروط قرارداد اصلی درباره تغییر ترکیب کنسرسیوم، انتقال سهم و جایگزینی عضو استخراج می شود و برای هر شرط، اقدام مشمول موافقت، مرجع دارای اختیار صدور موافقت، شرایط پذیرش درخواست و زمان تحقق آثار حقوقی آن تعیین خواهد شد. سپس مقررات انتقال اجباری و خروج عضو در توافق داخلی با شروط مربوط به موافقت سرمایه‌پذیر دولتی در قرارداد اصلی تطبیق داده می شود. در ادامه، آثار موافقت یا عدم موافقت بر وضعیت انتقال، استمرار تعهدات پیشین عضو خارج شده و مسئولیت عضو جایگزین براساس حقوق حاکم بررسی خواهد شد. مقررات فصل نهم اصول یونیدروا درباره انتقال حقوق، تعهدات و قرارداد نیز در این بخش مورد استفاده قرار می گیرد (UNIDROIT, 2016).

تحلیل تطبیقی در هر یک از پنج محور پژوهش براساس موضوع حقوقی مشترک انجام می شود. برای هر موضوع، ابتدا مفاد شرط قراردادی مربوط استخراج شده و سپس قواعد حقوق ایران و انگلستان درباره شرایط اعمال و آثار حقوقی آن بررسی خواهد شد. مقایسه در محور نخست بر مسئولیت ناشی از عدم تامین منابع مالی و آثار علت عدم پرداخت، در محور دوم بر ضمانت اجراهای مالی و حق رجوع اعضا، در محور سوم بر شرایط اعتبار و قابلیت اجرای ضمانت اجراهای موثر بر عضویت و سهم، در محور چهارم بر قلمرو مسئولیت تضامنی و حقوق سرمایه‌پذیر دولتی و در محور پنجم بر شرایط موافقت با خروج یا انتقال سهم و آثار آن بر تعهدات قراردادی متمرکز خواهد بود. در تحلیل آرای قضایی نیز موضوع اختلاف، مفاد شرط مورد رسیدگی، قاعده حقوقی اعمال شده و مبنای تصمیم دادگاه استخراج می شود.

اطلاعات گردآوری شده براساس پنج محور اهداف اختصاصی دسته بندی می شوند و برای هر حکم حقوقی، مشخصات منبع، ماده قانونی یا بند قراردادی، اشخاص مشمول، شرایط اعمال و آثار حقوقی آن ثبت خواهد شد. تحلیل مقررات قراردادی با مراجعه به متن شرط و قواعد حقوقی حاکم انجام می شود و در هر محور، مفاد قراردادهای نمونه با قوانین و آرای قضایی مرتبط در دو نظام حقوقی مورد مقایسه قرار می گیرد.

اهمیت و ضرورت پژوهش:

در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی که اعضای کنسرسیوم تعهدات مالی خود را براساس توافق داخلی تقسیم کرده اند، تعیین ضمانت اجراهای عدم تامین منابع مالی بر نحوه جبران کسری هزینه ها و تقسیم مسئولیت میان اعضا تاثیر دارد. شرایط مطالبه سهم پرداخت نشده، حق رجوع اعضایی که کسری منابع را تامین کرده اند و حدود اعمال ضمانت اجراهای موثر بر حقوق عضویت و سهم، از موضوعاتی هستند که باید در مقررات قراردادی پیش بینی شوند. بانک جهانی نیز بر هماهنگی شروط مربوط به مسئولیت و ضمانت اجرا با نحوه تقسیم تعهدات و ریسک های قراردادی تاکید کرده است (World Bank Group, 2017). بررسی این موضوعات از نظر تعیین حدود حقوق و تعهدات اعضا و کاهش اختلافات ناشی از اجرای شروط مالی مشارکت ضرورت دارد.

در قراردادهای منعقدشده با سرمایه‌پذیر دولتی، تعیین آثار عدم تامین منابع مالی بر مسئولیت منفرد و تضامنی اعضا نیز اهمیت حقوقی دارد، زیرا ممکن است سایر اعضا با مطالبه اجرای تعهداتی مواجه شوند که تامین منابع مربوط به آنها در توافق داخلی بر عهده عضو دیگری بوده است. همچنین خروج عضو یا انتقال اجباری سهم او می تواند تابع موافقت نهاد دولتی باشد و بر وضعیت تعهدات قراردادی اعضا اثر بگذارد. اسناد آنسیترال و مرکز اروپایی بررسی مشارکت های عمومی و خصوصی نیز به تنظیم مسئولیت سرمایه گذاران و شرایط تغییر ترکیب آنان در قراردادهای مشارکت با نهادهای عمومی پرداخته اند (UNCITRAL, 2019; EPEC, 2021). از این رو، تعیین شرایط اعمال ضمانت اجراها و آثار آنها بر مسئولیت اعضا در برابر سرمایه‌پذیر دولتی، برای تنظیم شروط تامین مالی، انتقال سهم و خروج اعضای مشارکت کاربرد دارد

پیشینه تحقیق (همراه با ذکر منابع اساسی)

مطالعات فارسی

پاسبان و قربانی زلیخایی (۱۳۹۶) با بررسی ماهیت حقوقی جوینت ونچر و مقررات گروه اقتصادی با منافع مشترک در حقوق ایران، به تحلیل حقوق و تعهدات اعضا در روابط داخلی و مسئولیت آنان در برابر اشخاص ثالث پرداختند. نویسندگان با مطالعه ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات قانون تجارت، وضعیت حقوقی مشارکت های قراردادی را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که جوینت ونچر شیوه ای برای همکاری اقتصادی و تقسیم هزینه ها و خطرات سرمایه گذاری میان چند شخص است که حقوق و تعهدات اعضای آن براساس قرارداد تشکیل مشارکت تعیین می شود. آنان توضیح دادند که قانونگذار ایران با پیش بینی گروه اقتصادی با منافع مشترک، شرایطی برای تشکیل این نوع همکاری ایجاد کرده و در عین حال، برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث محدودیت هایی در نظر گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که تعیین حدود مسئولیت اعضا در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث از موضوعاتی است که باید هنگام تنظیم قرارداد مشارکت مورد توافق قرار گیرد، زیرا در صورت سکوت قرارداد، مقررات قانون حاکم مبنای تشخیص مسئولیت خواهد بود. نویسندگان با استناد به ماده ۴۰۳ قانون تجارت، این دیدگاه را مطرح کردند که در صورت حاکمیت حقوق ایران بر جوینت ونچر، اصل بر نسبی بودن مسئولیت اعضاست و پذیرش مسئولیت تضامنی به مبنای حقوقی مربوط نیاز دارد.

رفیعی و رجبی (۱۴۰۰) با مطالعه تطبیقی معاذیر قراردادی در قراردادهای سرمایه گذاری نفت و گاز، آثار حوادث موثر بر اجرای تعهدات را براساس اسناد بین المللی و منطقه ای بررسی کردند. پژوهشگران میان شرایطی که وقوع یک حادثه مانع اجرای تعهد می شود و شرایطی که تغییر اوضاع و احوال، اجرای قرارداد را با دشواری مواجه می کند، تفکیک قائل شدند و مقررات مربوط به فورس ماژور و هاردشیپ را از نظر شرایط تحقق و آثار حقوقی مورد تحلیل قرار دادند. آنان همچنین نحوه تنظیم شروط معاذیر قراردادی را در چند نمونه از قراردادهای نفت و گاز بررسی کردند و تفاوت تعبیرهای مورد استفاده برای تعیین حوادث مشمول شرط و حقوق طرفین پس از وقوع آنها را توضیح دادند. یافته های پژوهش نشان داد که آثار حقوقی معاذیر قراردادی با توجه به نوع حادثه، شرایط پیش بینی شده در قرارداد و مقررات حاکم متفاوت است و نحوه تنظیم این شروط می تواند بر امکان استناد متعهد به مانع اجرای تعهد تاثیر بگذارد. نویسندگان همچنین معاذیر قراردادی را از شروط ثبات در قراردادهای نفتی تفکیک کردند و نتیجه گرفتند که برخی از شروط مورد استفاده در قراردادهای بررسی شده از نظر تعریف شرایط تحقق و تعیین آثار حقوقی نیازمند اصلاح و هماهنگی بیشتر با اسناد بین المللی و منطقه ای هستند.

رهائی، حسینی مقدم و فلاح خاریکی (۱۴۰۰) با مطالعه ماهیت حقوقی گروه اقتصادی با منافع مشترک، شباهت ها و تفاوت های این نهاد را با شرکت مدنی در فقه امامیه و سایر ساختارهای همکاری اقتصادی بررسی کردند. نویسندگان با روش توصیفی ـ تحلیلی، مقررات ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه را در کنار مبانی شرکت مدنی قرار دادند و وضعیت تشکیل گروه اقتصادی، ماهیت رابطه اعضا و آثار حقوقی آن را با جوینت ونچر و کنسرسیوم مقایسه کردند. در این بررسی، گروه اقتصادی با منافع مشترک به عنوان یکی از ساختارهای همکاری چند شخص برای انجام فعالیت اقتصادی مشترک مورد مطالعه قرار گرفت و مبانی ایجاد تعهدات اعضا، وضعیت شخصیت حقوقی و تفاوت های آن با شرکت مدنی بررسی شد. یافته های پژوهش بر شباهت این نهادها از نظر همکاری اقتصادی اعضا و وجود تفاوت در ساختار حقوقی و مقررات حاکم بر تشکیل و اداره آنها دلالت داشت. نویسندگان همچنین نشان دادند که شناسایی گروه اقتصادی با منافع مشترک در حقوق ایران، بررسی مستقل ماهیت آن را در مقایسه با شرکت مدنی و سایر نهادهای مشارکتی ضروری می سازد، زیرا آثار حقوقی فعالیت گروه و مسئولیت اعضا براساس قالب حقوقی حاکم بر آن تعیین می شود.

بازی، عامری نیا و بابایی (۱۴۰۱) با بررسی تطبیقی جوینت ونچر قراردادی و نهادهای مشابه در فقه امامیه و حقوق ایران، ماهیت حقوقی مشارکت مشترک قراردادی را براساس مقررات قانون مدنی و قانون تجارت تحلیل کردند. نویسندگان ابتدا جوینت ونچر شرکتی و قراردادی را از نظر شکل همکاری، شخصیت حقوقی و حقوق اعضا تفکیک کردند و سپس امکان انطباق نوع قراردادی آن را با شرکت مدنی موضوع مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدنی و شرکت عملی موضوع ماده ۲۲۰ قانون تجارت مورد بررسی قرار دادند. یافته ها نشان داد برخی قواعد شرکت مدنی در روابط اعضای جوینت ونچر قراردادی قابل استفاده است، ولی ماهیت الزام آور توافق مشارکت و امکان همکاری بدون ایجاد مالکیت مشاع نسبت به آورده ها، مانع انطباق کامل این دو نهاد می شود. نویسندگان همچنین توضیح دادند که شرکت های مشمول ماده ۲۲۰ قانون تجارت دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکا هستند، در حالی که تشکیل شخصیت حقوقی مستقل با ماهیت جوینت ونچر قراردادی و قصد معمول طرف های آن سازگاری ندارد. آنان در نهایت نتیجه گرفتند که برای تعیین ماهیت و آثار حقوقی جوینت ونچر قراردادی در حقوق ایران باید به اصل آزادی قراردادها، مواد ۱۰ و ۱۹۰ قانون مدنی و مقررات خاص سرمایه گذاری خارجی مراجعه کرد.

شیروی و عباسی وفایی (۱۴۰۱) با بررسی ساختار مالی مشارکت میان شرکت های ملی نفت و شرکت های بین المللی در عملیات اکتشاف بالادستی، نحوه تامین هزینه ها و تقسیم تعهدات مالی ناشی از مشارکت در عملیات مشترک را تحلیل کردند. نویسندگان وضعیتی را بررسی کردند که در آن شرکت بین المللی نفتی پس از انعقاد قرارداد بالادستی، مکلف می شود عملیات را با مشارکت شرکت ملی نفت انجام دهد و در قرارداد عملیات مشترک، سهم معینی نیز به شرکت ملی اختصاص می یابد. آنان توضیح دادند که انتقال بخشی از تعهدات و

ریسک های پذیرفته شده در قرارداد بالادستی به شرکت ملی نفت می تواند تعهدات شرکت بین المللی را کاهش دهد و با ساختار قرارداد اصلی ناسازگار شود. یافته های پژوهش نشان داد که سهم شرکت ملی نفت می تواند به صورت سهم تعهدشده تنظیم شود، به این معنا که هزینه های مربوط به سهم آن شرکت تا مرحله معینی از عملیات، که غالبا کشف تجاری است، توسط شرکت های بین المللی تامین می شود. براساس نتایج پژوهش، پس از رسیدن پروژه به مرحله مقرر، شرکت ملی نفت می تواند هزینه های پیشین را به صورت نقدی بازپرداخت کند یا این هزینه ها از محل سهم آن شرکت از نفت تولیدی بازیافت شود. نویسندگان نتیجه گرفتند که چنین ترتیبی امکان مشارکت شرکت ملی نفت در عملیات مشترک را فراهم می کند و در عین حال، تعهدات و ریسک های پذیرفته شده توسط شرکت های بین المللی در قرارداد بالادستی را حفظ می کند.

حجازی، نیک نژاد و تقی پور (۱۴۰۱) با بررسی مقررات مربوط به گروه اقتصادی با منافع مشترک در حقوق ایران، موانع حقوقی و فقهی تشکیل و فعالیت این نهاد را تحلیل کردند. نویسندگان با مطالعه ماده ۱۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه و قواعد شرکت مدنی، آثار قراردادی تشکیل گروه اقتصادی و وضعیت حقوقی اعضای آن را بررسی کردند و نشان دادند که قانونگذار با پیش بینی این نهاد، آزادی اعضا را در تنظیم قرارداد و انتخاب شیوه همکاری اقتصادی به رسمیت شناخته است. با این حال، قرار دادن گروه اقتصادی در قالب شرکت مدنی و فقدان شخصیت حقوقی مستقل، موجب بروز مسائلی درباره امکان برخورداری گروه از دارایی مستقل، اقامتگاه، تابعیت و سایر آثار شخصیت حقوقی می شود. یافته های پژوهش همچنین نشان داد که مقررات شرکت مدنی در قانون مدنی عمدتا به مالکیت مشاع و اداره اموال مشترک مربوط است و احکام جامعی درباره تشکیل، سازماندهی، اداره و انحلال یک گروه اقتصادی قراردادی ارائه نمی کند. نویسندگان با بررسی موارد سکوت و تعارض مقررات، نتیجه گرفتند که محدود بودن قواعد قانونی مربوط به ساختار گروه و روشن نبودن برخی آثار حقوقی فعالیت آن، از عوامل کاهش استفاده عملی اشخاص تجاری از این قالب مشارکت است.

فرامرزی، تاجیک و میری (۱۴۰۴) با مطالعه ماهیت قراردادهای جوینت ونچر در روابط بین المللی و مقایسه آنها با عقد مشارکت در حقوق ایران، جایگاه حقوق و تعهدات شرکا را در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک، به ویژه قراردادهای نفت و گاز، بررسی کردند. پژوهشگران با روش توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای، ویژگی های همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی در قالب مشارکت مشترک را مطالعه کردند و نقش آورده های نقدی و غیرنقدی، مدیریت مشترک فعالیت اقتصادی و تقسیم سود و زیان را در شکل گیری رابطه قراردادی مورد توجه قرار دادند. یافته های پژوهش نشان داد که جوینت ونچر از نظر مشارکت اشخاص در فعالیت اقتصادی و تقسیم منافع و زیان ها با عقد مشارکت در حقوق ایران شباهت دارد، ولی ویژگی های بین المللی قرارداد، محل استقرار طرف ها و شرایط استمرار همکاری می تواند موجب تفاوت در تنظیم روابط حقوقی آنها شود. نویسندگان همچنین نتیجه گرفتند که قراردادهای جوینت ونچر معمولا امکان همکاری طولانی مدت را

فراهم می کنند و ادامه رابطه قراردادی، در صورت فقدان سبب خاتمه، بر اساس توافق طرف ها تعیین می شود. در بررسی قراردادهای نفت و گاز نیز آنان جایگاه توافق اعضا را در تعیین آورده ها، اداره فعالیت مشترک و حقوق و تعهدات ناشی از مشارکت مورد توجه قرار دادند.

مطالعات خارجی

پریرا (۲۰۱۲) در پژوهشی درباره آثار عدم اجرای تعهدات مالی در مشارکت های بلندمدت نفتی، مقررات عدم پرداخت سهم هزینه ها و ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قراردادهای عملیات مشترک را بررسی کرد. وی با مطالعه قراردادهای نمونه مورد استفاده در صنعت نفت و قواعد حقوقی مربوط به عدم اجرای تعهد، شرایطی را تحلیل کرد که در آنها یکی از اعضای مشارکت، سهم خود از هزینه های عملیات را پرداخت نمی کند و سایر اعضا برای ادامه تامین مالی پروژه ناچار به جبران کسری می شوند. بخش قابل توجهی از پژوهش به ضمانت اجرای سلب سهم مشارکت اختصاص داشت و نویسنده اعتبار و قابلیت اجرای این ضمانت اجرا را با توجه به ارزش اقتصادی سهم و محدودیت های حقوقی حاکم بررسی کرد. یافته های پژوهش نشان داد که سلب سهم در برخی مراحل اجرای پروژه ممکن است نتیجه مالی متفاوتی برای اعضا داشته باشد، زیرا ارزش سهم مشارکت و میزان تعهدات مالی آینده در طول عمر پروژه تغییر می کند. پریرا همچنین به بررسی سازوکارهای جایگزین، از جمله تضمین های مالی، حقوق وثیقه ای و ترتیبات قراردادی وصول مطالبات پرداخت و نتیجه گرفت که استفاده از این ابزارها می تواند امکان وصول تعهدات مالی را در شرایطی فراهم کند که اجرای شرط سلب سهم با محدودیت حقوقی یا مشکلات عملی مواجه می شود.

رابرتز (۲۰۱۶) با بررسی مقررات عدم ایفای تعهد در قراردادهای عملیات مشترک نفت و گاز، شرایط تحقق عدم پرداخت و ضمانت اجراهای قراردادی آن را تحلیل کرد. وی توضیح داد که مفهوم عدم ایفای تعهد در بسیاری از قراردادهای عملیات مشترک، به پرداخت نکردن سهم هزینه هایی مربوط می شود که اپراتور برای تامین مالی عملیات مشترک از اعضا مطالبه کرده است. پژوهش با مطالعه ساختار درخواست های تامین وجه و تعهدات پرداخت اعضا، شرایط فعال شدن مقررات عدم پرداخت، مهلت رفع آن و اقداماتی را بررسی کرد که در طول استمرار عدم ایفای تعهد قابل اعمال هستند. رابرتز همچنین نقش مرحله اجرای پروژه را در رفتار مالی اعضا مورد توجه قرار داد و نشان داد که تمایل عضو به تامین هزینه های اکتشاف، توسعه یا تولید می تواند با توجه به ارزش اقتصادی پروژه و امکان دستیابی به درآمدهای آینده متفاوت باشد. در تحلیل ضمانت اجراهای قراردادی، وی به ضرورت حفظ امکان تامین مالی عملیات مشترک و آثار حقوقی شروط سلب سهم پرداخت و نتیجه گرفت که نحوه تعریف عدم ایفای تعهد، تشریفات اعمال ضمانت اجرا و شرایط قراردادی مربوط به تغییر حقوق عضو، در قابلیت اجرای مقررات عدم پرداخت تاثیر دارند.

پالکینگهورن (۲۰۱۶) با بررسی مقررات انتقال سهم و تغییر کنترل در قراردادهای عملیات مشترک نفتی، نحوه تنظیم حقوق و تعهدات اعضا را هنگام انتقال تمام یا بخشی از سهم مشارکت تحلیل کرد. وی با تمرکز بر قرارداد نمونه بین المللی عملیات مشترک سال ۲۰۱۲ و مقایسه آن با نسخه های پیشین، سهم مشارکت را مجموعه ای از حقوق، منافع، تعهدات و مسئولیت های ناشی از قرارداد عملیات مشترک و قرارداد مبنای بهره برداری مورد مطالعه قرار داد. نویسنده سپس شرایط انتقال سهم به اشخاص ثالث، تغییر کنترل شرکتی و آثار این تغییرات بر ساختار همکاری اعضا را بررسی کرد. در این تحلیل، وضعیت خروج سرمایه گذاران از پروژه، نیاز آنان به تامین نقدینگی، تغییر سیاست سرمایه گذاری و بروز مشکلات مالی از جمله شرایطی بود که می توانست به انتقال سهم منتهی شود. یافته های پژوهش نشان داد که مقررات انتقال سهم در نسخه ۲۰۱۲ قرارداد نمونه نسبت به نسخه های پیشین جزئیات بیشتری پیدا کرده و شرایط انتقال حقوق و تعهدات اعضا را گسترده تر تنظیم کرده است. نویسنده همچنین توضیح داد که انتقال سهم مشارکت می تواند بر وضعیت تعهدات قراردادی عضو و حقوق سایر اعضا اثر بگذارد و آثار آن باید با توجه به مقررات قرارداد عملیات مشترک و قرارداد مبنای فعالیت نفتی تعیین شود.

ریچی و کوناین (۲۰۱۸) با بررسی شروط موثر بر حقوق مالکانه اعضا در قراردادهای عملیات مشترک، مقررات نسخه های ۱۹۸۹ و ۲۰۱۵ قرارداد نمونه انجمن آمریکایی متخصصان زمین نفتی را از نظر نحوه تنظیم و حمایت از حقوق اعضا مقایسه کردند. پژوهشگران مقررات مربوط به منافع مالکانه اعضا در محدوده قرارداد و خارج از آن، محدودیت های انتقال سهم، شرایط تحصیل حقوق جدید و اعتبار شروط قراردادی موثر بر مالکیت را بررسی کردند. آنان علاوه بر مقایسه متن قراردادهای نمونه، آرای قضایی و تحولات حقوقی پس از انتشار نسخه ۱۹۸۹ را مطالعه کردند تا آثار اصلاحات نسخه ۲۰۱۵ بر روابط حقوقی اعضا تعیین شود. یافته های پژوهش نشان داد که شروط قراردادی مربوط به انتقال و تحصیل سهم در طول اجرای عملیات مشترک، برای حفظ ساختار همکاری اعضا و تنظیم حدود اختیار آنان در واگذاری حقوق مالکانه به کار می روند. نویسندگان همچنین نتیجه گرفتند که اعتبار و قابلیت اجرای این شروط به ماهیت حقوق مالکانه موضوع قرارداد، نحوه تنظیم محدودیت ها و قواعد حقوقی حاکم بستگی دارد و اصلاحات قرارداد نمونه ۲۰۱۵ نیز باید در چارچوب این قواعد مورد ارزیابی قرار گیرد.

پریرا (۲۰۱۹) با تحلیل تطبیقی مقررات عدم ایفای تعهد در قراردادهای عملیات مشترک نفت و گاز، قابلیت اجرای ضمانت اجراهای ناشی از پرداخت نکردن سهم هزینه ها را در نظام های حقوقی مختلف بررسی کرد. وی ابتدا دلایل پیش بینی مقررات عدم پرداخت در قراردادهای عملیات مشترک، شرایط تحقق عدم ایفای تعهد، تشریفات اعلام آن و مهلت جبران پرداخت را مطالعه کرد و سپس ضمانت اجراهای مربوط به سلب سهم، خرید اجباری، حقوق وثیقه ای، انتقال سهم و خروج عضو را از نظر آثار حقوقی مورد ارزیابی قرار داد. در بخش

تطبیقی، نویسنده تفاوت رویکرد نظام های کامن لا و حقوق نوشته را نسبت به اجرای شروط قراردادی موثر بر حقوق مالی اعضا بررسی کرد و نشان داد که مقررات عدم پرداخت ممکن است در نظام های مختلف با محدودیت های حقوقی متفاوتی مواجه شوند. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که قابلیت اجرای ضمانت اجراهای قراردادی به متن شرط، ماهیت حقوقی اقدام پیش بینی شده، حقوق حاکم و شرایط اقتصادی مشارکت وابسته است. پریرا همچنین نشان داد که مقررات سلب سهم و سایر ضمانت اجراهای شدید باید از نظر آثار مالی آنها بر عضو و کارکردشان در تامین هزینه های عملیات مشترک بررسی شوند و سازوکارهایی مانند خرید سهم، ایجاد وثیقه یا انتقال حقوق مشارکت می توانند نتایج حقوقی متفاوتی نسبت به سلب بلاعوض سهم داشته باشند.

پریرا و پاپا (۲۰۱۹) با بررسی مقررات عدم ایفای تعهد، انتقال سهم و خروج عضو در قراردادهای عملیات مشترک، شرایط حقوقی پایان عضویت در مشارکت را تحلیل کردند. نویسندگان این سه سازوکار را از نظر مبنای قراردادی، شرایط اعمال و آثار حقوقی با یکدیگر مقایسه کردند و نشان دادند که هر یک هدف و شرایط متفاوتی دارد، هرچند اجرای آنها ممکن است به خروج یک عضو از قرارداد عملیات مشترک منتهی شود. در این بررسی، وضعیت انتقال حقوق و تعهدات عضو، شرایط پایان مشارکت و آثار مالی خروج مورد توجه قرار گرفت و موضوعاتی مانند جبران مالی عضو خارج شده و استمرار مسئولیت های قراردادی او پس از خروج بررسی شد. پژوهشگران همچنین رابطه میان مقررات انتقال سهم و خروج از قرارداد را تحلیل کردند و توضیح دادند که شیوه پایان عضویت می تواند بر میزان حقوق مالی قابل دریافت و تعهدات باقی مانده عضو تاثیر بگذارد. یافته های مطالعه نشان داد که آثار خروج عضو باید با توجه به سازوکار قراردادی منجر به خروج تعیین شود و تفاوت مقررات عدم ایفای تعهد، انتقال سهم و خروج اختیاری، نتایج متفاوتی از نظر جبران مالی و مسئولیت قراردادی ایجاد می کند.

ماهسنه (۲۰۲۴) با بررسی مسئولیت منفرد و تضامنی اعضای مشارکت مشترک در قراردادهای عمرانی مبتنی بر شرایط فیدیک، قواعد حقوق قطر را با اصول قراردادهای تجاری بین المللی یونیدروا مقایسه کرد. نویسنده بند ۱.۱۴ شرایط فیدیک را از نظر مسئولیت اعضای مشارکت در برابر کارفرما، شرایط معرفی نماینده مشارکت و آثار تقسیم وظایف اجرایی میان اعضا مورد بررسی قرار داد. وی سپس قواعد مربوط به تعدد متعهدان در قانون مدنی قطر و اصول یونیدروا را تحلیل کرد و شرایط اعمال این قواعد را در قراردادهایی سنجید که پیمانکار از چند عضو تشکیل شده است. یافته های پژوهش نشان داد که میان حقوق قطر و اصول یونیدروا از نظر بسیاری از قواعد ماهوی مسئولیت تضامنی تفاوت عمده ای وجود ندارد، ولی ماهیت تعهدات اجرایی در قراردادهای مشمول شرایط فیدیک موجب می شود بخش قابل توجهی از قواعد عمومی تعدد متعهدان در عمل کاربرد محدودی داشته باشند. نویسنده همچنین نشان داد که تقسیم مسئولیت های اجرایی میان اعضای

مشارکت، دامنه تعهد تضامنی آنان در برابر کارفرما را تغییر نمی دهد و تغییر اعضای مشارکت طبق شرایط فیدیک به موافقت کارفرما وابسته است. در بخش دیگری از پژوهش، وضعیت تبدیل تعهدات اجرایی به تعهدات مالی بررسی شد و نتیجه آن بود که قواعد مربوط به مسئولیت تضامنی و حق رجوع میان اعضا، هنگام مطالبه مبالغ مالی ناشی از عدم اجرای قرارداد کاربرد بیشتری پیدا می کنند.

کبیل (۲۰۲۵) با بررسی سیر تحول قراردادهای عملیات مشترک در صنعت نفت و گاز، ساختار شروط قراردادی مورد استفاده برای تنظیم همکاری شرکت های سرمایه گذار را مطالعه کرد. وی با مرور منابع حقوقی و قراردادی، شکل گیری قراردادهای عملیات مشترک و تحول آنها را در ارتباط با نیاز شرکت های نفتی به تقسیم هزینه ها، خطرات عملیاتی و مسئولیت های ناشی از اکتشاف و تولید بررسی کرد. یافته های پژوهش نشان داد که قرارداد عملیات مشترک با تعیین تعهدات مالی و اجرایی اعضا، نحوه تصمیم گیری درباره عملیات و شرایط مشارکت در هزینه ها، چارچوب اداره فعالیت مشترک را تنظیم می کند. نویسنده همچنین نشان داد که شروط عدم ایفای تعهد و انتقال سهم در کنار سایر مقررات قراردادی، برای تعیین حقوق اعضا در شرایط تغییر وضعیت مشارکت به کار می روند و آثار آنها به شرایط پیش بینی شده در قرارداد وابسته است. در بررسی تحول قراردادهای نمونه نیز مشخص شد که مقررات مربوط به مسئولیت اپراتور، تصمیم گیری درباره عملیات و وضعیت حقوق مشارکت اعضا در طول زمان توسعه یافته و جزئیات بیشتری پیدا کرده اند.

مارتین، گیلبرت و رابرتز (۲۰۲۵) در بررسی اختلافات ناشی از عدم پرداخت سهم هزینه ها در مشارکت های حوزه انرژی و منابع طبیعی، تعهد اعضا به تامین به موقع منابع مالی و ضمانت اجراهای قراردادی عدم انجام آن را تحلیل کردند. نویسندگان با مطالعه مقررات مشارکت های مشترک و اختلافات حقوقی مربوط به اجرای آنها، نشان دادند که پرداخت نکردن سهم هزینه ها می تواند تامین مالی عملیات مشترک و اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای مبنای بهره برداری را تحت تاثیر قرار دهد. آنان سپس ضمانت اجراهایی را بررسی کردند که برای مواجهه با عدم پرداخت در توافق مشارکت پیش بینی شده اند و اعتبار و قابلیت اجرای آنها را با توجه به آرای دادگاه ها و مراجع داوری مورد توجه قرار دادند. در این تحلیل، ضمانت اجراهایی که موجب محرومیت عضو از حقوق اقتصادی یا از دست دادن سهم مشارکت می شوند، از نظر شدت آثار و شرایط حقوقی اجرا بررسی شدند. نسخه به روزشده این مطالعه در اکتبر ۲۰۲۵، آرای دادگاه های انگلستان در اختلاف TAQA Bratani v Fujairah Oil and Gas را نیز در بحث عدم اجرای تعهد مالی و سلب سهم در قراردادهای عملیات مشترک بررسی کرد. نتایج مطالعه نشان داد که اجرای ضمانت اجراهای عدم پرداخت به مفاد قرارداد، ماهیت حقوقی ضمانت اجرا و قواعد حقوقی حاکم بستگی دارد و در مورد شروطی که آثار مالی سنگینی برای عضو پرداخت نکرده دارند، امکان اعمال محدودیت های حقوقی بر اجرای ضمانت اجرا باید مورد توجه قرار گیرد.

منابع

بازی، نسرین، عامری نیا، محمدباقر، و بابایی، داریوش. (۱۴۰۱). بررسی تطبیقی ماهیت جوینت ونچر قراردادی با نگاهی بر فقه امامیه و قوانین مدنی و تجارت ایران. پژوهشنامه حقوق تطبیقی، ۶(۱)، ۳۹–۵۷.

پاسبان، محمدرضا، و قربانی زلیخایی، مجید. (۱۳۹۶). حقوق، تعهدات و مسئولیت های شرکا در قراردادهای جوینت ونچر با تاکید بر گروه اقتصادی با منافع مشترک. نشریه قضاوت، (۹۰)، ۱–۳۱.

حجازی، داود، نیک نژاد، جواد، و تقی پور، بهرام. (۱۴۰۱). موانع حقوقی و فقهی پذیرش عملی نهاد گروه اقتصادی با منافع مشترک در نظام حقوقی و اقتصادی ایران. فقه و مبانی حقوق اسلامی، ۵۵(۲)، ۲۸۹–۳۰۶.

رفیعی، محمدتقی، و رجبی، عیسی. (۱۴۰۰). مطالعه تطبیقی فورس ماژور و هاردشیپ در قراردادهای سرمایه گذاری نفت و گاز با تاکید بر اسناد بین المللی و منطقه ای. مطالعات حقوق انرژی، ۷(۲).

رهائی، مجید، حسینی مقدم، سید حسن، و فلاح خاریکی، مهدی. (۱۴۰۰). ماهیت حقوقی گروه منفعت اقتصادی و تمیز آن با شرکت مدنی در فقه امامیه و سایر نهادهای مشابه. تحقیقات مالی اسلامی، (۲۱)، ۱۶۵–۱۸۸.

شیروی، عبدالحسین، و عباسی وفایی، مهدی. (۱۴۰۱). ساختار مالی مشارکت میان شرکت های ملی و شرکت های بین المللی در عملیات اکتشاف بالادستی نفتی. مطالعات حقوق تطبیقی، ۱۳(۲)، ۶۳۳–۶۵۱.

فرامرزی، احسان، تاجیک، اکرم، و میری، حمید. (۱۴۰۴). بررسی قرارداد جوینت ونچر یا عقد مشارکت در روابط بین الملل با مطالعه موردی قراردادهای نفت و گاز در حقوق ایران. مطالعات روابط بین الملل، ۱۸(۷۱)، ۲۲–۳۹.

Conine, G. B., & Ritchie, A. (2018). Property provisions of the joint operating agreement: An update for the new 2015 form JOA. Texas Tech Law Review, 50(3), 489–571. https://digitalrepository.unm.edu/law_facultyscholarship/649/

European PPP Expertise Centre (EPEC). (2021). EPEC guide to public-private partnerships. European Investment Bank. https://doi.org/10.2867/8101

Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and describing what we do: Doctrinal legal research. Deakin Law Review, 17(1), 83–119. https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70

International Chamber of Commerce. (2024). ICC model contracts consortium agreement (construction/infrastructure) (Publication No. 835E). ICC. https://iccwbo.org/business-solutions/model-contracts-clauses/icc-model-consortium-agreement-construction/

International Institute for the Unification of Private Law. (2016). UNIDROIT principles of international commercial contracts 2016. UNIDROIT. https://www.unidroit.org/wp-content/uploads/2021/06/Unidroit-Principles-2016-English-i.pdf

Kabil, A. M. (2025). Development of joint operating agreements in the oil and gas industry, and their key provisions: A brief analysis. South Asian Journal of Social Sciences and Humanities, 6(4), 49–62. https://doi.org/10.48165/sajssh.2024.6403

Mahasneh, N. (2024). Joint and several liability at the interface of national and international law and the FIDIC conditions of contract. Uniform Law Review, 29(3), 412–428. https://doi.org/10.1093/ulr/unae039

Martin, A. T., Gilbert, J., & Roberts, P. (2025). Default. In Joint venture disputes in the energy and natural resource sectors (updated version, pp. 157–222). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/law-iic/9780192859617.003.0010_update_001

Michaels, R. (2019). The functional method of comparative law. In M. Reimann & R. Zimmermann (Eds.), The Oxford handbook of comparative law (2nd ed., pp. 345–389). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198810230.013.11

Pereira, E. G. (2012). Protection against default in long term petroleum joint ventures (OIES Paper WPM 47). Oxford Institute for Energy Studies. https://doi.org/10.26889/9781907555473

Pereira, E. G. (2019). Enforceability of default provisions under joint operating agreements. Houston Journal of International Law, 41(2), 285–341.

Pereira, E. G., & Pappa, M. (2019). The effects of default, transfer, and withdrawal provisions on JOA exits: Should I stay or should I go? International Energy Law Review, 2019(2), 39–47. https://nottingham-repository.worktribe.com/output/1527198/the-effects-of-default-transfer-and-withdrawal-provisions-on-joa-exits-should-i-stay-or-should-i-go

Polkinghorne, M. (2016). Transfer of interest and change of control in JOAs. In E. G. Pereira (Ed.), Understanding joint operating agreements (pp. 207–246). Intersentia. https://doi.org/10.1017/9781780684536.015

Roberts, P. (2016). Making the default mechanism fair and enforceable. In E. G. Pereira (Ed.), Understanding joint operating agreements (pp. 331–346). Intersentia. https://doi.org/10.1017/9781780684536.019

UK Supreme Court. (2015). Cavendish Square Holding BV v Talal El Makdessi; ParkingEye Limited v Beavis [2015] UKSC 67. https://www.supremecourt.uk/cases/uksc-2013-0280

UNIDROIT. (2016). UNIDROIT principles of international commercial contracts 2016. International Institute for the Unification of Private Law. https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2016/

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (2019). UNCITRAL legislative guide on public-private partnerships. United Nations. https://uncitral.un.org/en/lgppp

World Bank Group. (2017). Guidance on PPP contractual provisions, 2017 edition. World Bank. https://ppp.worldbank.org/library/guidance-ppp-contractual-provisions-2017-edition

World Bank. (n.d.). Joint development agreement termsheet. Public-Private Partnership Resource Center. https://ppp.worldbank.org/ppp-overview/practical-tools/checklists-and-risk-matrices/joint-venture-termsheet

نتیجه و کاربرد پژوهش:

نتایج پژوهش بر تعیین شرایط اعمال ضمانت اجراهای حقوقی و قراردادی در صورت عدم تامین منابع مالی مورد تعهد یکی از اعضای مشارکت و آثار آن بر مسئولیت اعضا در برابر سرمایه‌پذیر دولتی متمرکز خواهد بود. در این چارچوب، آثار علت عدم تامین بر مسئولیت قراردادی عضو، حدود مطالبه خسارت و حق رجوع سایر اعضا، شرایط اعمال ضمانت اجراهای موثر بر حقوق عضویت و سهم و تاثیر موافقت سرمایه‌پذیر دولتی بر خروج عضو یا انتقال سهم او بررسی می‌شود. کاربرد نتایج پژوهش در تنظیم و اصلاح شروط قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی، به ویژه مقررات مربوط به تامین سهم مالی اعضا، جبران کسری منابع، تعیین ارزش سهم در انتقال اجباری و شرایط تغییر ترکیب کنسرسیوم خواهد بود. همچنین نتایج حاصل می‌تواند در تفسیر قراردادها و رسیدگی به اختلافات میان اعضای مشارکت یا میان آنان و سرمایه‌پذیر دولتی، برای تعیین حدود مسئولیت قراردادی و حقوق قابل مطالبه هر یک از طرف‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

برنامه و زمانبندی انجام طرح:

برآورد هزینه ها:

ردیف	نوع هزینه	مبلغ
۱	لوازم مصرف نشدنی	
۲	خرید کتاب و نشریه و نظایر آن	
۳	مواد و لوازم مصرف شدنی	
۴	انتشارات (حداکثر طبق آئین نامه)	
۵	جمع کل	

مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی ـ پژوهشی گروه

فرم پیشنهاد پایان نامه در تاریخ.....در شورای تحصیلات تکمیلی ـ پژوهشی گروه مطرح و نظر کمیته به شرح زیر اعلام می شود.

تصویب شد ☐ نیاز به اصلاح دارد ☐ به تصویب نرسید ☐

امضاء مدیر گروه

تاریخ: